

1500479-47.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500479-47.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500479-47.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154012/2022 - DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 25414249 -

DEL.SEC.PRES.PRUDENTE PLANTÃO, 2154012 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 8

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Gabriel da Silva

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de GABRIEL DA SILVA, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 07 de junho de 2022, por volta das 00h01min, na Avenida Manoel Romeu Caires, nº 299, Bloco F2, apartamento 02, Humberto Salvador, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente - SP, GABRIEL DA SILVA tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida por maconha, em formato de tijolo, com massa total líquida aproximada de 488,38 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e trinta e oito centigramas).

Segundo a acusação, o denunciado tinha em depósito no apartamento situado no local dos fatos a porção de maconha em formato de tijolo acima descrita, com a finalidade de fracioná-la e destiná-la ao consumo de terceiros.

Policiais Militares receberam através do Copom informações de que um indivíduo

branco, sem camisa, havia recebido certa quantidade de droga, a qual estava fracionando e comercializando no local. Assim diligenciou a Polícia até o endereço apontado.

Ao perceber a presença policial, o denunciado correu para o interior do apartamento, entrou e fechou a porta. Ele foi seguido pelos policiais, que foram atendidos no local por sua companheira, que disse que estava sozinha no imóvel. Autorizados pela companheira do denunciado, os policiais entraram no apartamento, onde encontraram o denunciado deitado sobre a cama, como se estivesse dormindo. Indagado, o denunciado admitiu aos policiais que possuía a porção de maconha em formato de tijolo sob o colchão da cama, onde a droga foi localizada, confessando, ainda, que a droga era destinada à comercialização.

Em poder do denunciado também foi encontrada a quantia de R\$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais).

Afirma que as circunstâncias do delito, a existência de informações sobre a prática do crime de drogas no local, a grande quantidade de droga apreendida em poder do denunciado, indicam com saciedade que a droga se destinava à comercialização.

Em audiência de custódia realizada aos 07/06/2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 58/63).

Denúncia recebida aos 30/06/2022 (fls. 150).

Citado, o réu apresentou resposta à acusação, sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante e nulidade das provas obtidas, ou a rejeição da denúncia ante a não configuração do delito de tráfico. Pleiteou a concessão de liberdade provisória. (fls. 190/201).

A fls. 214/222, indeferido pelo E. TJSP pedido de Habeas Corpus impetrado pelo acusado para a revogação da prisão preventiva.

Por decisão de fls. 223/225, o recebimento da denúncia foi confirmado com a manutenção da prisão preventiva do acusado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial a ilegalidade da atuação policial por invasão de domicílio e uso indevido de algemas; e a desclassificação do delito do artigo 33 da Lei de Drogas para o previsto no artigo 28 do mesmo diploma.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, afasto a tese de nulidade da prisão em flagrante pela suposta invasão do domicílio aventada pela informante, pois os relatos dos policiais em juízo foram firmes no sentido de que a entrada no imóvel foi franqueada pela companheira do acusado, o qual correu para o interior da casa ao avistar a guarnição.

Os demais elementos de prova igualmente contradizem a versão dada por Thaynara Cristina Alves em juízo, já que sua afirmação de que a porta da casa foi arrombada pelos policiais foi rechaçada pelo depoimento da testemunha Pedro Henrique, o qual afirmou que a porta estava intacta após a ação policial.

As fotos do local da ocorrência tampouco demonstram qualquer avaria que indique a entrada forçada tal qual narrado pela informante. Seu depoimento em juízo, assim, restou isolado nos autos.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa está demonstrada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/08); pelos boletins de ocorrência (fls. 32/36 e 162/169); pelo auto de exibição/apreensão (fl. 39); pelo laudo pericial (fls. 43/45); bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

Ouvida na condição de informante, Thaynara Cristina Alves disse em juízo que estava presente no dia dos fatos, que ocorreu em seu apartamento. Explicou que se levantou para beber água, enquanto Gabriel dormia com as crianças quando os policiais

chegaram e perguntaram quem estava em casa. Alegou que os policiais entraram na casa, pegaram Gabriel e o levaram para a cozinha. Disse que a droga foi encontrada no quarto. Relatou que as crianças estavam no quarto em que a droga foi encontrada. Afirmou que o quarto era dela, que os policiais informaram que encontraram a droga embaixo da cama. Disse que estavam separados na época do fato, mas que reataram três dias antes. Sobre seu depoimento na Delegacia disse que quando foi levada informaram que ela estava presa. Negou que a assinatura apresentada em juízo no depoimento seja dela. Informou que assinou um documento quando estava com o Delegado com o nome por extenso. Alegou que o primeiro contato com os policiais foi na cozinha, mas que ainda não estavam dentro da residência. Narrou que os policiais pediram para entrar na casa, para abrir a porta. No entanto, explicou que quando foi abrir a porta um dos policiais já pulou a janela. Disse que os policiais abriram a porta. Na sequência relatou que os policiais informaram que tinha uma denúncia, que havia uma arma. Relatou que os policiais perguntaram sobre arma para Gabriel. Explicou que os policiais acharam a droga, mas que nesse momento estava na sala com Gabriel. Negou que estava presente quando encontraram a droga. Disse que os móveis e a janela foram quebrados pelos policiais. Negou que Gabriel tenha tentado brigar ou correr. Afirmou que presenciou um xingamento. Alegou que os policiais forçaram para entrar, que chegou a arrombar a porta. Relatou ainda, que tirou as fotos da residência, mas não da porta arrombada. Por fim, disse que não abriu a porta para os policiais e que mesmo assim entraram.

A testemunha Valdemir Otávio dos Santos, policial militar, disse em juízo que foram acionados via COPOM de que um indivíduo sem camisa, branco, estaria na porta do apartamento realizando a venda de entorpecentes. Disse que se deslocaram até o local, que quando se aproximaram o indivíduo percebeu a presença dos policiais e adentrou o imóvel. Alegou que a porta foi fechada e que bateram na porta. Ainda, disse que a esposa apareceu na janela e que perguntaram quem estava na casa. Na sequência disse que ela relatou que estava com os filhos. Informou que perguntaram se podiam entrar, e que foi autorizado por ela. Relatou que ela abriu a porta e que o rapaz estava deitado fingindo que estava dormindo. Sustentou que o rapaz fingia que estava dormindo, que o indagaram. Informou que o rapaz disse que estava fumando maconha na frente do apartamento. Explicou que foi encontrado sob o colchão meio quilo de maconha, a qual ele relatou ter pagado R\$ 400,00 e que a esposa acompanhou a busca. Disse que a denúncia informava um rapaz branco de 1,70 de altura. Narrou que foi realizado boletim de ocorrência. Aduziu que o acusado disse informalmente que usava a droga e vendia, que tinha um grupo de vários irmãos que faziam parte da facção criminosa naquele bairro. Alegou que na abordagem ele estava agitado pela expressão corporal. Afirmou que a droga estava sob o colchão que o acusado apontou o local. Entretanto, disse que realizaram a busca e localizaram. Descreveu que era um apartamento, que eram conjuntos aglomerados. Esclareceu que quando a pessoa presta o depoimento, mas não quer assinar colocam o seu depoimento que "recusou". Narrou que a venda seria na porta do apartamento. Relatou que o indivíduo adentrou para a casa de forma rápida. Aduziu teve uma confissão informal de que vendia o entorpecente. Informou que relataram para a autoridade policial da confissão informal. Disse que a busca aconteceu em toda a residência, que já se encontrava desorganizada. Explicou que tinha colchão no chão, coisas jogadas, cano da janela. Relatou que o acusado estava agressivo e que após a busca foi colocada a algemada devido ao receio de fuga. Disse que quando o policial estava realizando a busca para evitar alguma coisa contra a integridade física acabou utilizando as algemas. Relatou que estava na sala com o acusado enquanto o outro policial realizava a busca. Informou que durante a diligência familiares foram ajudar a ficar com as crianças, que foi uma senhora. Negou que tenham arrombado a porta da residência. Com a imagem apresentada em juízo disse que se a porta fosse arrombada não estaria dessa forma e que era impossível entrar pela janela. Explicou que não tem como o policial passar pela janela e que a esposa abriu a porta do apartamento.

A testemunha Fabiano Alves de Oliveira, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento próximo ao Humberto Salvador quando foi irradiado via COPOM que nos predinhos da CDHU tinha um indivíduo que estaria traficando, sem camisa e perto do apartamento nº 2. Alegou que se deslocaram até o local e que o indivíduo ao

avistar os policiais adentrou a residência e trancou a porta. Informou que fizeram a aproximação e que a esposa apareceu na janela e que perguntaram se estava tudo bem. Narrou que ela relatou que estava com os filhos e que perguntaram se poderiam entrar na casa. Informou que adentraram e que no quarto estava o acusado fingindo que estava dormindo. Alegou que realizaram a abordagem que nada de ilícito foi encontrado, mas que ele estava agitado. O réu disse que entrou porque estava com maconha e indicou que a guardara sob o colchão. O tijolo pesava cerca de 500g, a amásia disse não saber de nada porque tinham reatado há pouco tempo. Deram voz de prisão e os levaram à delegacia. O réu assumiu a propriedade. Não se lembra se Thaynara assinou o boletim. Acontece muito de os abordados confessarem o delito aos policiais e alterarem a versão quando ouvidos na delegacia. Quando a pessoa está impossibilitada ou se recusa a assinar o boletim de ocorrência, constam essa situação. Não sabe dizer a idade das crianças que estavam no local.

A testemunha Pedro Henrique Benites dos Santos Souza narrou em juízo que não viu a entrada da polícia na casa, apenas a saída. Foi até lá porque ouviu barulho de vidro quebrando e uma vizinha avisou que a polícia estava na casa deles. Desceu por conta das crianças e bateu na porta chamando por Thaynara. O policial mandou que deixasse o local e assim fez. Minutos depois o policial voltou na porta e gritou, acredita que chamando a testemunha. Perguntou-lhe quem era e explicou que é irmão de Thaynara por parte de pai e foi até lá para retirar as crianças. Pediram-no que entrassem na casa e os explicasse sobre um telefone celular que as crianças teriam pego. Perguntou à sua sobrinha e disseram que não tinham pego. Levantou a roupa das crianças e nada foi encontrado. Subiu com as crianças. Verificou que o réu tinha marcas no corpo como se tivesse sido agredido. O réu estava sem camisa. A vizinha o comunicou que a polícia procurava uma arma no local. O réu parecia ter lesões na barriga e nas costas. Quando bateu na porta ela estava encostada. Após levarem o réu e Thaynara para a delegacia, pegou alguns documentos na casa e o celular de sua sobrinha. A porta estava sem a chave, apenas a encostou. A polícia entrou de forma silenciosa pois não ouviu nada além dos vidros quebrando. Todas as janelas tem grade, menos a da cozinha. A porta da casa não estava arrombada. Para ingressar na residência, tem que ser pela porta, não pode ser pela janela.

O réu Gabriel da Silva, interrogado em juízo, disse que a droga era sua mas não era para tráfico. Já foi pego por usar drogas e teve que assistir palestras e pagar multa. Acordou no dia com um tapa no rosto do policial. Foi agredido com rasteira e chutes na perna. O policial xingou sua esposa e o levou para a sala, batendo mais em sua perna. Mostrou a droga para a polícia e entregou para eles. Pegaram o celular do réu e mexeram. Jogaram os móveis no chão. Fecharam a porta da sala com o réu dentro e bateram pedindo por mais. Perguntaram se queria dar uma volta na viatura com eles. Ameaçaram de prender sua esposa. Pediram que delatasse o vendedor da droga, mas se recusou por medo de represália. Também foi agredido com soco no rosto. Não sabe por que não apareceram essas lesões no laudo pericial. Não falou nada na audiência de custódia por medo de que fizessem algo com sua esposa. Sua esposa disse que os policiais apareceram na janela e perguntaram por ele. Ela confirmou e eles pularam para dentro. A janela da cozinha é de correr, é possível a entrada. Compra entorpecente em grande quantidade para não ter de ir muitas vezes na "biqueira". Já teve problemas com a justiça, mas estava de boa. Pagou R\$ 400,00 pela droga. Estava sem camisa no dia dos fatos. Não sabe de algum motivo que os policiais teriam para prejudicá-lo. Ganhava cerca de 1.500 reais a cada 15 dias com seu trabalho. Nunca integrou o PCC. O réu e seus irmãos sempre foram perseguidos pelos policiais. Lembra de já ter sido abordado pelo policial Otávio. O réu e Thaynara haviam reatado relacionamento há cerca de 10 ou 15 dias. A casa era bem organizada, mesmo porque têm crianças.

Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a

execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão da droga (488,38g de maconha) no apartamento em que o réu se encontrava e após este indicar a sua localização (sob um colchão).

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais militares.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça. Os policiais narraram em uníssono, quando ouvidos em juízo, que receberam informação irradiada via COPOM dando conta de que o "um rapaz branco e sem camisa" estava a comercializar entorpecentes próximo à entrada do apartamento nº 02 daquele conjunto habitacional. Aportando ao local, localizaram o denunciado nas exatas condições mencionadas na denúncia anônima, sendo que este correu e adentrou o apartamento ao notar a presença dos policiais.

Ato contínuo, procedeu-se à apreensão do entorpecente tal qual narrado acima. Desse modo, in casu, o modo em que estava acondicionado o entorpecente e toda a quantidade de droga apreendida (488,38g de maconha), bem como o fato de ter sido localizado dinheiro (R\$ 169,00) com o réu, sem explicação plausível tampouco comprovação de sua origem lícita, levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável afirmar que destinava-se ao consumo pessoal do réu.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amealhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No caso dos autos, o réu foi autuado em flagrante portando maconha em quantidade completamente incompatível com o uso próprio.

Some-se a isso o fato de que, no momento de sua abordagem, o réu confessou aos milicianos que parte da droga se destinava à venda (fl. 33).

Evidente, pois, que sua destinação era o fornecimento a terceiros, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes. Demais disso, a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Mesmo que consideremos o fato do acusado ser usuário de drogas, tal condição não afasta a qualificação de traficante, pois não é incomum usuários traficarem para sustentar o próprio vício e ainda obter algum lucro.

Sob este parâmetro vale colacionar as seguintes decisões:

Tráfico. Absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Desclassificação. Inviável - A condição de usuário não exclui a mercancia ilícita. Impossível maior aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas - Pena e regime mantidos. Recurso Improvido". (TJ-SP - APL: 75984020118260286 SP 0007598-40.2011.8.26.0286, Relator: Aguinaldo de Freitas Filho, Data de Julgamento: 05/07/2012, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/07/2012, grifei).

A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP: RJTJSP 101/498).

No que se refere a quantidade de entorpecentes, destaco que o Departamento Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos realizou um estudo técnico no ano de 2014, com vistas a sistematizar dados e informações a respeito do uso de entorpecentes (disponível em: https://site.mppr.mp.br/arquivos/File/Projeto_Semear/Consultas/Consulta_01_2019/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf).

Nesse estudo, ficou demonstrado que um cigarro de maconha é produzido utilizando-se entre 0,5 a 1,5 gramas de maconha.

No caso dos autos, o laudo pericial indicou a massa líquida de 488,38 gramas (fls. 44), de modo que seria possível a produção de até 976 cigarros de maconha, o que se revela quantidade significativa de entorpecentes, a caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes.

Esse mesmo estudo apresenta uma tabela indicando os parâmetros utilizados em diversos países para que a apreensão de entorpecente seja considerada como compatível com o uso, sendo na Alemanha (até 30g), Bélgica (até 3g), Colômbia (até 20g), Estados Unidos (até 28,45, em alguns Estados), Finlândia (até 15g), Holanda (até 5g), México (até 5g), Paraguai (até 10g), Portugal (até 25g) e até mesmo no Uruguai, onde o uso de maconha é permitido, cada pessoa pode adquirir até 40 gramas por mês.

Veja-se, portanto, que a quantidade de maconha apreendida com o réu é muito maior que a permitida em vários países, sendo, inclusive, mais de 10 vezes superior ao limite mensal por usuário no Uruguai, onde o uso da substância é permitido, não podendo ser considerada para uso próprio.

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu ostenta maus antecedentes criminais, ante a condenação definitiva no processo 0010741-21.2017.8.26.0482 (fato anterior ao crime em análise, com trânsito em julgado posterior - fl 51).

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face

da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade da droga não impõem maior reprovabilidade na conduta do réu.

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, diante dos maus antecedentes do acusado, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, razão pela qual mantenho a pena intermediária no patamar já fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento.

Por outro lado, presente a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu é tecnicamente primário, motivo pelo qual diminuo a pena em 2/3, totalizando 02 (dois) anos e (01) mês de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do réu no patamar de 02 (dois) anos e (01) mês de reclusão

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 208 (duzentos e oito) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. Não obstante a pena aplicada seja inferior a quatro anos, o art. 33, § 3º, do CP, determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", e, no presente caso, se está diante de réu portador de maus antecedentes, com uma condenação com trânsito em julgado pelo delito de furto qualificado, o que revela ser necessário a fixação de regime mais gravoso que o permitido considerando apenas o montante da pena.

Incabível a substituição (art. 44, CP), em razão da condenação anterior, com trânsito em julgado, o que indica que a substituição não seria suficiente, conforme art. 44, inciso III, do CP. Do mesmo modo, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), em razão da pena aplicada ser superior ao limite fixado no CP. Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu GABRIEL DA SILVA a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena privativa de liberdade consistente em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como a pagar 208 (duzentos e oito) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois as condições que levaram à sua

prisão ainda estão presentes, sendo a sua custódia imperativa para o resguardo da ordem pública. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a periculosidade do réu é idônea para amparar a custódia cautelar de modo a assegurar a ordem pública. No caso, a gravidade em concreto do delito impõe a necessidade da segregação cautelar. Rememore-se que o réu é portador de maus antecedentes, ostentando condenação com trânsito em julgado pelo crime de furto qualificado, e ainda foi autuado nos autos em testilha em flagrante com o objetivo de disseminar o tráfico de drogas, sendo apreendido com nada menos que 488,38 g de maconha. Assim, se for colocado em liberdade, haverá sério risco à ordem pública.

Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomendo-o na prisão em que se encontra, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Também deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Além disso, decreto o perdimento dos valores apreendidos (R\$ 169,00), o que faço com fulcro no art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, devendo ser revertidos diretamente ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006).

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da justiça gratuita, que ora concedo ao acusado. Anote-se.

Em caso de recurso, expeça(m)-se guia(s) de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeçam-se guias de execução definitiva ou, sendo o caso, ofícios de aditamento às guias de execução;
- 4) Encaminhe-se à Senad a relação dos bens apreendidos, declarados perdidos em favor da União (art. 63, § 4º, da Lei 11.343/2006);
- 5) Expeça-se Guia de Recolhimento da União-GRU, UG 200246, Gestão 00001, código 20201, relativamente ao depósito judicial de fl. 89, e a encaminhe por ofício ao Banco do Brasil para recolhimento, comunicando à Senad por meio do e-mail cdc.funad@mj.gov.br.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA